

刑法  
No.303

## 共通問題 H26-20

(配点：3)

月 日

月 日

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

## 【事例】

甲は、知人のAをだまして、A所有の土地・建物（以下「本件不動産」という。）を時価よりも割安な価格で入手した上、他人に転売しようと考えた。そこで、甲は、Aに対し、実際にはそのような事実はないのに、「本件不動産は、現在は公表されていないが、大規模な地盤沈下のおそれのある地域にある。」と伝え、「公表される前に、俺が買ってやる。」と言った。Aは、元々、本件不動産を子供に相続させるつもりであり、他人に売り渡すつもりはなかったが、甲の言葉を信じ、低額でも処分しようと思い、某月1日、甲との間で、通常取引価額の半額程度である2000万円で購入する旨の売買契約を締結した。そして、甲は、同月3日、本件不動産の自己への所有権移転登記を行うとともに、本件不動産の売買代金として、現金2000万円をAに支払い、同月5日、本件不動産の引渡しを受けた。

その後、甲は、乙との間で本件不動産に関する売買の交渉を行ったが、その過程で、乙は、甲がAをだまして相当安い価格で本件不動産を入手したことを知った。しかし、乙は、甲から、売買代金として通常取引価額よりも低額である3000万円を提示されたことから、同月20日、甲との間で本件不動産の売買契約を締結し、同日、乙への所有権移転登記を行った。

一方、甲は、知人の丙に前記売買代金として現金3000万円を受け取らせ、B銀行の甲名義の預金口座に直ちに同代金を入金させることとし、同月18日、その旨を丙に指示した。丙は、それまでの経緯を知らないまま、甲の指示に従い、同月20日、乙から現金3000万円を受領した。ところが、丙は、多額の借金を抱えており、B銀行に向かう途中、「この現金を元にもうけして借金返済に充てよう。」と考え、競馬場に行き、乙から受領した現金の全額を馬券購入に充てた。すると、総額で1000万円のもうけが出たので、丙は、同月21日、現金3000万円をB銀行の甲名義の預金口座に入金し、もうけに相当する現金1000万円を自己の借金返済に充てて費消した。

## 【記述】

- ア. 甲には、本件不動産の自己への所有権移転登記が完了した時点で、詐欺既遂罪が成立する。  
 イ. 甲が本件不動産の乙への所有権移転登記を行った行為には、横領罪が成立する。  
 ウ. 乙には、本件不動産の自己への所有権移転登記が完了した時点で、詐欺既遂罪の幫助犯が成立する。  
 エ. 乙が本件不動産を譲り受けた行為には、盗品等有償譲受け罪が成立する。  
 オ. 丙は甲に財産上の損害を与えていないので、丙に横領罪は成立しない。

|          |            |     |     |     |     |     |
|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| №303     | 詐欺、横領及び盗品等 |     |     |     |     | 正答率 |
| 共通H26-20 | 正解         | ア 1 | イ 2 | ウ 2 | エ 1 | オ 2 |
|          |            |     |     |     |     | 50% |

## ア 正しい

不動産に対する詐欺罪の既遂時期は、占有移転時又は所有権移転登記完了時とされている（大連判大11.12.15）。よって、甲には本件不動産の自己への所有権移転登記が完了した時点で、詐欺既遂罪が成立する。

## イ 誤っている

本件不動産についてのAの所有権は、甲による詐欺行為（事前行為）により既に侵害されている。その後、本件不動産を甲が乙に譲渡し、所有権移転登記を行ったとしても（事後行為）、事後行為の違法性は、事前の状態犯（事前行為）によって評価し尽くされている。よって、事後行為については、横領罪（252条1項）は成立しない（不可罰的事後行為）。

## ウ 誤っている

幫助犯（62条1項）の幫助行為は正犯の実行行為以前又はそれと同時に行われるものであり、正犯の実行が終わった後においては成立しない。本事例では、甲が本件不動産を詐取した時点では乙は甲の行為に全く関与しておらず、また、乙が本件不動産の売買の交渉を行い、売買契約を締結して、自己への所有権移転登記をしたという一連の行為を行ったときには、既に甲の行った詐欺罪の実行行為は終了していたのであるから、乙には詐欺既遂罪の幫助犯は成立しない。

## エ 正しい

本件不動産は、詐欺罪（246条1項）という「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる（256条1項）。それを乙は甲から「有償で譲り受け」ている（256条2項）。乙は、本件不動産が、詐欺によって甲が領得したものであることを認識しており、故意も認められる。よって、乙が本件不動産を譲り受けた行為には、盗品等有償譲受け罪（256条2項）が成立する。

## オ 誤っている

委託物横領罪（252条1項）の客体は、自己が（委託関係に基づいて）占有する他人の物である。①物であること、②自己が占有すること、③その占有が委託に基づくこと、④それが他人の物であることが必要である。本事例では、①現金が物に当たる点、②丙が現金を占有している点、③その占有が甲の委託に基づく点については問題なく認められる。④について、民事法上、金銭の所有者と占有者は一致すると解されている（最判昭39.1.24）が、刑法上は寄託された金銭の所有権は寄託者に帰属すると解されている。また、当該現金は、盗品等の売却代金であり、民法上、寄託者の返還請求権が否定される（民法708条本文参照）反射的效果として、その所有権は受寄者に帰属すると解されている（最大判昭45.10.21）が、刑法上は占有者にとっては他人の物と解されている（最判昭23.6.5、百選Ⅱ63事件等）。よって、④の要件も充たされる。よって、丙が乙から受領し、所持している現金3000万円は、「自己の占有する他人の物」に当たる。そして、丙が、乙から受領した現金全額を馬券購入に充てた行為は、不法領得の意思を実現する行為に当たり、「横領」に当たる。よって、丙には横領罪が成立する。なお、丙は、翌21日、現金3000万円をB銀行の甲名義の預金口座に入金し、返還をしてはいるが、乙から受領した現金全額を馬券購入に充てた時点で横領罪が成立しており、丙による返還行為は丙の罪責とは関係がない。